

1503919-63.2021.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Justiça de São Paulo:

"Apelação Criminal -Tráfico de entorpecente- Nulidade do processo e da prova coligida porque a busca domiciliar fez-se sem autorização judicial -Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade "ter em depósito" é crime permanente - A ocorrência de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem autorização judicial -Tipificação- A prova oral, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503919-63.2021.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503919-63.2021.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2259606/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 20421463 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2692/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2259606 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2692/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 072/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Avaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESUS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

JESUS DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei

11.343/06, sob a acusação de que, na manhã de 22 de setembro de 2021, por volta das 07h30min, na Avenida Brasília, número 420, Vila Jardim, e na Rua Piraju, número 180, Parque Filgueiras, neste município e Comarca de Avaré, com o envolvimento do adolescente Wesley de Aquino Cazonato, tinha em depósito em sua residência 07 (sete) porções de cocaína, com peso de 0,85g (oitenta e cinco centigramas), e outras 39 (trinta e nove) porções da mesma droga na residência do adolescente, com peso de 16,10g (dezesesseis gramas e dez centigramas), conforme laudo de exame químico-toxicológico a fls. 106/109, substância que causa dependência, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS).

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/120. Por decisão proferida em 23 de setembro de 2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 63/66). Mandado de prisão cumprido a fls. 87/88. A denúncia foi oferecida em 07 de outubro de 2021 e o réu, notificado a fls. 148, ofereceu Defesa Prévia a fls. 151. Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021, oportunidade na qual também foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 153/155). Em audiência, foram inquiridas 03 testemunhas de acusação e o réu interrogado (fls. 201/202 e gravações audiovisuais).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 206/211). A douta Defesa, por sua vez, em sede preliminar pleiteou pelo reconhecimento da nulidade processual por violação de domicílio na casa do adolescente Wesley. No mérito, pugnou pela absolvição da ré com fundamento no artigo 386, inciso VI, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do delito para o crime de porte de drogas e, em caso de eventual condenação, pela aplicação da pena em seu patamar mínimo legal, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de Drogas, bem como pela fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos (fls. 214/232).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "havia notícias de que o denunciado estaria envolvido com o tráfico de drogas. Mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos número 1503900-57.2021.8.26.0073, a DISE Avaré se dirigiu até a residência do denunciado. No local, JESUS tinha em depósito 07 (sete) porções de cocaína, uma lâmina utilizada para fracionar a droga, embalagens plásticas e R\$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) em espécie e notas diversas. Sabedores do envolvimento do denunciado com o adolescente Wesley de Aquino Cazonato para a venda de drogas, em diligência à residência de Wesley, poucos metros do local dos fatos, foram encontradas outras 39 (trinta e nove) porções da mesma droga e a mesma lâmina e embalagens plásticas utilizadas pelo denunciado para fracionamento das substâncias, sendo o adolescente apreendido em auto próprio. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro". De prêmio, a preliminar de nulidade de provas alegada pela Defesa não merece prosperar. A entrada dos policiais na residência do adolescente não ocorreu de forma irregular, tampouco o flagrante foi ilegal não havendo, pois, se falar em irregularidade e/ou nulidade.

Ora, o ingresso dos policiais na residência do adolescente, sem autorização judicial, não está eivado por qualquer mácula. Primeiramente, porque não há comprovação de que a entrada não foi permitida. De fato, não há qualquer menção nos autos de resistência ao ingresso dos agentes por parte dos residentes.

Em adição, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal prevê que a busca domiciliar não prescinde de mandado judicial, salvo nas hipóteses excepcionais, constitucionalmente previstas, dentre elas o caso de flagrante delito. Como é cediço, o ato análogo ao tráfico de entorpecentes é crime permanente e, em caso de flagrante de crime dessa natureza é possível a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Assim, era perfeitamente lícito aos policiais, incumbidos do combate à criminalidade, adentrar na casa onde a droga estava sendo fracionada. Não se pode cogitar, por conseguinte, na ilicitude das provas obtidas, pois o momento

consumativo do delito de traficância se prolonga no tempo. A respeito da prescindibilidade do mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, há sedimentada jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616/TO; Relator Ministro Gilmar Mendes). Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Apelação Criminal -Tráfico de entorpecente- Nulidade do processo e da prova coligida porque a busca domiciliar fez-se sem autorização judicial -Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade "ter em depósito" é crime permanente - A ocorrência de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem autorização judicial -Tipificação- A prova oral, a quantidade e a variedade de forma do entorpecente apreendido em poder dos réus asseguram que a droga se destinava à venda . Consumação .Para a consumação do crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal (misto alternativo Ausência de elementos seguros a indicar que os acusados estivessem associados para traficar Liame subjetivo de caráter estável não caracterizado Recursos desprovidos" (Apelação Criminal n.º 990.08.160355-1 rel. Desembargador José Raul Gavião de Almeida) (g.n.).

Ora, finda a instrução processual, restou claro que a abordagem foi motivada pela suspeita de traficância.

Inquestionável que a ação dos agentes da lei se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

No mérito, à luz da prova produzida, a denúncia procede integralmente.

A materialidade delitativa restou configurada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 01/02, boletim de ocorrência a fls. 03/07, auto de exibição e apreensão a fls. 18/19, fotografias a fls. 25/28, laudo de constatação provisória a fls. 46/48, laudo toxicológico a fls. 106/109, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitativa, de igual modo, também restou incontestada e recai sobre o réu. A testemunha de acusação Fernando Mantovani Tavares, policial civil, em juízo, disse "que investigações apontavam a prática do tráfico de drogas pelo réu com o envolvimento do adolescente. Em cumprimento ao mandado de busca domiciliar localizaram porções de crack, lâminas utilizadas para fracionamento da droga e dinheiro na residência do acusado. Ele admitiu o tráfico. Durante a diligência outra equipe recebeu informação anônima de que o adolescente Wesley, vizinho do acusado, praticava o tráfico junto do acusado. Na residência de Wesley encontraram trinta e oito porções da mesma droga e as mesmas lâminas utilizadas para fracionamento da substância. Tanto na residência do adolescente quanto na do acusado, o armazenamento da droga era idêntico (pote amarelo de M&M). Houve autorização por escrito da genitora do adolescente".

A testemunha de acusação Valdemir Alcides Matias, policial civil, judicialmente, corroborou a versão de seu colega policial. Acrescentou "que antes da ocorrência nunca tinham visto o adolescente com Jesus e que não havia nenhuma investigação em relação a ele".

O adolescente Wesley, sob o crivo do contraditório, negou a prática do tráfico de drogas em conjunto com o réu. Relatou "que a droga estava com o acusado e que "colocaram" a droga na sua casa. Falou que conhece o réu apenas "de vista" e que não sabe se ele vende drogas. Disse que as lâminas de barbear encontradas eram suas. Falou que a Polícia Civil entrou em sua casa e exibiu a droga, mas que a droga não estava ali".

O réu Jesus da Silva, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Disse "que a droga se destinava ao seu uso e que não conhecia o adolescente".

Com efeito, a negativa de autoria do réu nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais, além da prova da materialidade.

Nesse contexto, a versão do acusado além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que ele nada produziu, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação, não havendo, pois, qualquer razão para desacreditá-los. Nesse sentido: "... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.). Assim, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelo réu. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (46 pedras de crack), das lâminas comumente utilizadas para fracionar droga, do modo pelo qual estava acondicionada, bem como da localização de dinheiro, cuja origem lícita o réu não comprovou.

Ressalte-se, ainda, que conquanto o adolescente Wesley tenha negado seu envolvimento com o crime, certo é que, nos autos do processo infracional nº 1503925-70.2021.8.26.0073, em trâmite perante a Justiça da Infância e Juventude desta Comarca, comprovou-se sua participação no delito, mormente porque as drogas estavam embaladas e acondicionadas da mesma maneira daquelas apreendidas com o réu, não sendo crível a alegação de que sequer se conheciam, visto que eram vizinhos, tendo-lhe sido aplicada a medida sócio-educativa de Liberdade Assistida pelo período de 01 ano.

Outrossim, os depoimentos prestados pelas testemunhas, da fase inquisitiva à judicial, foram firmes e seguros, não se vislumbrando qualquer interesse em acusar ou prejudicar o réu, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada. Não se pode conceber a justificativa rasa de que os policiais permanecem perseguindo cidadãos e atribuindo-lhes a propriedade de quantia tão grande de entorpecente com o único fim de prejudicar o réu. Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.).

De mais a mais, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

De igual modo, a causa especial de aumento descrita no inciso VI (envolver adolescente) do art. 40 da lei de Drogas está devidamente comprovada nos autos

tanto que, como já dito anteriormente, o adolescente respondeu a processo infracional tendo-lhe sido aplicada a medida sócio educativa de Liberdade Assistida. Neste ínterim, ressalte-se ser absolutamente fantasiosa as alegações do menor no sentido de que as drogas "foram plantadas" pelos policiais em sua casa, eis que seria demasiada coincidência crer que a Polícia Civil teria as mesmas embalagens (pote amarelo de M&M) para acondicionar as drogas e coloca-las na residência do adolescente, com o fim único e exclusivo de introduzi-lo na prática ilícita.

Desta feita, merece reprovação maior a conduta perpetrada pelo réu, eis que, em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral, utilizou-se do seu relacionamento com a adolescente, disseminando droga em sua vida e atrelando-o ao comércio espúrio de entorpecentes em detrimento de uma vida correta, pautada pelos estudos e trabalho honesto, mostrando a ele lucro fácil na tentativa de lhe desvirtuar do caminho que deve percorrer os cidadãos de bem.

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que o réu praticava o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JESUS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. Art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (F.A. e certidões a fls. 161/163), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI (envolvimento de adolescente), da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por outro lado, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa ou de que esteja presente a habitualidade delitiva. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confirma-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44,

parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, REVOGO a prisão preventiva decretada a fls. 63/66, podendo o réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República, oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu, e providencie-se o necessário para o cumprimento da sanção penal imposta. Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias e efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA